

0000046-95.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... e R\$ 300,00 por 12 horas diárias no tráfico.

Amaro (policial), em juízo, informou que a ré foi avistada próximo em local conhecido como ponto de tráfico, a mesma tentou se evadir e em seu poder foi achada uma bolsa contendo porções de cocaína, maconha e "crack" e dinheiro. A ré confessou que estava vendendo drogas há poucos dias. Não lembra de ter outra pessoa com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0000046-95.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000046-95.2021.8.26.0537

2021/000194

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Nayara Gonzaga Simão

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

NAYARA GONZAGA SIMIÃO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 61, inc. II, alínea "j", porque no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 10:30 horas, na Rua José Vicente, n.º 111, Bairro Inamar, adquiriu, trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, cocaína, "crack" e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foi concedida liberdade provisória à acusada, por decisão da juíza de plantão, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 39/41). A ré apresentou defesa prévia (fls. 77/78), sendo recebida a denúncia em 21.02.22 (fls. 86/87). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de março de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21, n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21, n.º

2646/22 e n.º 2650/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo provimento CSM n.º 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. A ré foi interrogada no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, que seja afastada a redução do art. 33, §4.º em razão de condenação posterior e fixação de regime fechado.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação que seja afastada a agravante da pandemia, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, aplicação da detração penal com fixação de regime aberto e substituída por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fl. 10), a ré confessou a prática do crime. Declarou ser usuária de maconha. Disse que passou a traficar para ajudar financeiramente a família, que recebia de R\$ 200,00 a R\$ 300,00 por 12 horas diárias de trabalho e que estava traficando há mais ou menos um mês.

Em juízo, permaneceu calada. Está sendo processada por outro tráfico, mas nunca foi condenada. Nada tem contra os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), relataram que em patrulhamento se depararam com a ré, que estava com uma bolsa, se assustou ao ver a viatura e tentou empreender fuga. Narraram que perseguiram a ré, sem perdê-la de vista, e a abordaram. Disseram que em revista na bolsa da ré localizaram 24 porções de cocaína, 46 pedras de "crack", 39 porções de maconha e a quantia de R\$ 174,00.

Falaram que a ré confessou e informou que recebia entre R\$ 200,00 e R\$ 300,00 por 12 horas diárias no tráfico.

Amaro (policial), em juízo, informou que a ré foi avistada próximo em local conhecido como ponto de tráfico, a mesma tentou se evadir e em seu poder foi achada uma bolsa contendo porções de cocaína, maconha e "crack" e dinheiro. A ré confessou que estava vendendo drogas há poucos dias. Não lembra de ter outra pessoa com a ré.

Maycon (policial), em juízo, afirmou que abordaram a ré e dentro da sacola que a mesma dispensou, durante a fuga, havia drogas, divididas em porções. Não se lembra se havia dinheiro. A ré confessou o tráfico. Narrou que conhecia a ré de vista, porque é moradora da região. Disse que um rapaz tentou se evadir, foi abordado e alegou que apenas passava pelo local. O local é conhecido como ponto de tráfico.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 07 - 46 pedras de "crack", 24 invólucros de cocaína e 39 porções de maconha) e diversidade ("crack", cocaína e maconha), o que é incompatível com a condição de usuária e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro (fls. 08 - R\$ 174,00), que a ré confessou o tráfico na fase policial, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes.

Porém, foram uníssonos no sentido de que as drogas foram apreendidas em poder da ré e que a mesma confessou o tráfico. Portanto, não é caso de absolvição.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (46 pedras de "crack", 24 invólucros de cocaína e 39 porções de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação da acusada, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 21/23) e laudo definitivo (fls. 83/85).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada à ré, que segundo consta dos autos é primária (fls. 102/104). Os processos em andamento não podem ser considerados por ofensa ao princípio do estado de inocência, observando, que embora tenha condenação definitiva o trânsito em julgado ocorreu em 20.01.22 (fls. 99), ou seja, após a prática deste crime (em 09.02.21).

Nesse sentido:

"Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar, para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores ao fato em causa ou com ele contemporâneas, tais como, por exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes processos que tenham tido o desate após o crime ventilado no feito (JUTACRIM 45/221). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 29/356, 30/414" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 334). Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica da acusada.

Compenso a agravante de ter sido cometido o crime em ocasião de estado de calamidade (pandemia Coronavírus/Covid-19) com a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito a decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE

POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (46 pedras de "crack", 24 invólucros de cocaína e 39 porções de maconha, já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos), posto que é primária, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º). A condenação posterior não demonstra que à época destes fatos a ré se dedicava a atividades criminosas.

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e §3.º., do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque a ré é primária, não ostenta antecedentes criminais, confessou na fase policial, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO NAYARA GONZAGA SIMIÃO à pena de 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e diante da situação econômica da ré.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A acusada poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primária e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiária da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 08; 55/57) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à bolsa de cor azul e sem marca aparente, apreendida (fls. 09), já periciada (fls. 81/82), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 42), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.
Diadema, 04 de abril de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA